

1501218-61.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... das elementares dos delitos de tráfico de substância entorpecente e resistência, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito de tráfico de drogas vem demonstrada no auto de exibição e apreensão a pág. 33/34 (pochete, mochila, anotações de contabilidade, dinheiro e droga), nos laudos de constatação às págs.36/39, químicos-toxicológico às págs.103/105 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501218-61.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501218-61.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156851/2022 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 25463537 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2156851 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR HENRIQUE CARDOSO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

HIGOR HENRIQUE CARDOSO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº11.343/06 e 329, caput, do Código Penal, porque no dia 08 de junho de 2022, por volta das 11h55min, na Travessa do Sol, bairro Montanhão, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, trazia consigo e guardava drogas consistentes em 324,01g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em 182 frascos plásticos e 210 invólucros plásticos; 203,37g de cocaína, acondicionadas em 125 invólucros plásticos e 196 eppendorfs; 26,18g de cocaína na forma de crack, acondicionadas em 249 eppendorfs; e 800ml de cloreto de metileno/diclorometano, substância vulgarmente conhecida como lança-perfume, acondicionadas em 84 frascos plásticos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 33/34, laudo de constatação de págs. 36/39 e laudos de exame químico-toxicológico definitivo de págs. 103/105 e 114/116.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, HIGOR HENRIQUE CARDOSO DA SILVA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais civis Wagner Amorim de Souza e Claudinei Cardozo da Silva, funcionários competentes para executá-lo.

Segundo o apurado, na data e local acima indicados, o acusado trazia consigo e guardava 1.046 (mil e quarenta e seis) embalagens individuais de drogas. Policiais civis receberam a informação de que um indivíduo, que ostenta uma tatuagem no rosto com a inscrição "Nathan", estaria praticando o crime de tráfico de drogas na Travessa do Sol, no bairro Montanhão, desenvolvendo a função de "abastece", expressão utilizada para fazer referência aos responsáveis pelo abastecimento de pontos de venda de substâncias entorpecentes.

De acordo com as pesquisas investigativas, aquele logradouro já havia sido alvo de ocorrências anteriores versando sobre tráfico de drogas.

Por isso, os policiais se dirigiram ao endereço acima mencionado, fizeram breve campanha com uma viatura descaracterizada e visualizaram o acusado subindo uma escadaria, portando uma pochete e carregando uma mochila nas costas. Mesmo à distância, os policiais conseguiram ver que HIGOR ostentava uma inscrição tatuada no rosto.

Por isso, eles saíram no encalço do acusado e se identificaram como policiais, instante em que ele atirou a mochila que trazia consigo ao solo. Visando evitar a abordagem, HIGOR investiu contra os policiais civis e entrou em luta corporal com eles, durante a qual caiu ao solo com o policial Claudinei. Então, foi detido e algemado, oportunidade em que os policiais confirmaram que ele possuía o nome "Nathan" tatuado na testa.

Em revista na mochila dispensada ao solo pelo acusado, os policiais encontraram cento e oitenta e dois frascos contendo maconha, cento e vinte e cinco invólucros plásticos com cocaína, duzentos e dez invólucros plásticos de maconha, cento e noventa e seis eppendorfs contendo cocaína, duzentos e quarenta e nove eppendorfs com pedras de crack, e oitenta e quatro frascos plásticos contendo lança-perfume.

Já no interior da pochete, havia a quantia de R\$ 105,00 (cento e cinco reais) e dois pedaços de papel com anotações alusivas à contabilidade do tráfico de drogas. Indagado, o acusado negou exercer a função de "abastece", afirmando que estava apenas trabalhando no local.

Nestas circunstâncias, HIGOR foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

A quantidade das drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a apreensão de dinheiro e de anotações referentes à contabilidade da mercancia espúria, bem

como as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante revelam a prática do tráfico de entorpecentes.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial a págs.05/71. Notificado (pág.121), o acusado ofertou defesa prévia a pág.125. Recebida a denúncia às págs. 126/127, o réu foi regularmente citado a pág.130. Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu. A acusação requer a condenação do réu nos termos da denúncia; ao passo que a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória. É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares dos delitos de tráfico de substância entorpecente e resistência, não havendo dúvidas quanto à autoria. A materialidade do delito de tráfico de drogas vem demonstrada no auto de exibição e apreensão a pág. 33/34 (pochete, mochila, anotações de contabilidade, dinheiro e droga), nos laudos de constatação às págs.36/39, químicos-toxicológico às págs.103/105 (maconha e cocaína) e págs. 114/116 (lança-perfume), bem como no comprovante de depósito de págs.62 (repetido a pág. 117).

Quanto à autoria, nas duas fases da persecução penal o acusado confessou o seu envolvimento no tráfico de drogas (págs.11/12 e nesta audiência).

Na Delegacia de Polícia, aduziu que:

“não é responsável pelo abastecimento de drogas, sendo apenas 'funcionário' de indivíduo cujo nome desconhece...”.

Em Juízo, mantendo a confissão, afirmou que realmente foi abordado no local do fato, onde há ponto de venda de droga, na posse da quantidade e espécie de substância entorpecente indicada na denúncia. Era o responsável pela venda da droga no local. O dinheiro era oriundo da mercancia ilícita.

Praticou a conduta porque enfrentava dificuldade financeira.

O réu confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

“Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão vem corroborada sob o crivo do contraditório nos depoimentos dos policiais civis Wagner Amorim de Sousa e Claudinei Cardozo da Silva, que em relato coeso e harmônico com o anterior, relataram os passos da diligência encetada na data dos fatos e espancaram qualquer dúvida quanto à autoria:

Realizadas investigações, receberam informação de que indivíduo que ostentava uma tatuagem no rosto com a inscrição “Nathan” (o que se verificou no rosto do acusado durante a audiência) praticava o tráfico de droga no local do fato, conhecido ponto de mercancia ilícita (viela com 'escadão') e desempenhava a função de “abastece”,

expressão utilizada para se referir aos responsáveis do abastecimento dos pontos de venda de drogas.

Dirigiram-se ao local e viatura descaracterizada e realizaram breve campanha.

Avistaram, então, o acusado. HIGOR portava uma pochete e carregava uma mochila nas costas. Cercaram o local.

O policial Claudinei abordou primeiramente o réu, verificando a mencionada tatuagem em seu rosto. A fim de evitar a sua prisão, o acusado passou a agredir o agente da lei, levando-o ao solo em luta corporal. O réu ofertava extrema resistência. Nesse momento, o policial Wagner chegou no local e o auxiliou para conter o agente, o que foi difícil.

Controlada a situação, em vistoria na mochila e na pochete foi localizada elevada quantidade de porções individuais de maconha, cocaína, crack e lança-perfume, além de anotações contendo a contabilidade típica do tráfico de droga e dinheiro trocado.

Inquirido, o acusado admitiu o seu envolvimento no tráfico, afirmando que estava no local para vender a droga. Negou desempenhar a função de 'abastece'.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

Inexiste o mínimo indício de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha: "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015).

A não oitiva de usuário ou civis não é incomum, diante da lei do silêncio que impera nas Comunidades e da dinâmica dos fatos apurada em instrução.

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a quantidade e a espécie da substância entorpecente apreendida (392 porções de maconha, 321 porções de cocaína, 249 invólucros plásticos de crack e 84 frascos de lança-perfume, totalizando 1.046 porções de drogas), a forma como acondicionada (individualmente), a apreensão de dinheiro e de anotações de contabilidade típicas da mercancia ilícita, o local da abordagem (conhecido ponto de mercancia ilícita) e as circunstâncias da prisão tornam evidente que a droga destinava-se ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal, conforme preconiza o artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.

Cumpra anotar que a circunstância do réu não ter sido preso no momento em que efetuava a venda da droga que portava, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

O crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, não sendo exigível, necessariamente, a prática de atos onerosos, pois suficiente a identificação da finalidade mercantil.

Não se olvida a alegação a justificativa ofertada pelo acusado para a prática do delito: Dificuldade financeira.

Não merece guarida a tese do estado de necessidade.

A dificuldade financeira, por si só, não autoriza a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida.

Cabia ao acusado demonstrar situação de extrema necessidade e que agira visando se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa (CPP, art.156). De tal ônus o réu não se desincumbiu a contento.

Não há prova de que o acusado não teria condições de encontrar forma lícita para a obtenção de sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)". (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

O crime de resistência também se configurou. O réu opôs-se à execução de ato legal, entrando em luta corporal com os policiais, visando impedir sua abordagem e prisão.

Não houve a chamada 'resistência passiva'.

O policial Claudinei afirmou que o acusado não aceitou a prisão, afirmando que era foragido (autos nº 0009295-51.2015.8.26.0482 - roubo majorado - 3ª Vara Criminal de

Presidente Prudente. Trânsito em julgado em 15/02/2017. Cumpria pena em regime semiaberto quando se evadiu em 03/01/2022, cf. certidão criminal de págs. 41/43 e folha de antecedentes de págs. 44/46) e não queria voltar ao estabelecimento prisional, entrando em luta corporal. Caíram no chão, inclusive, momento em que recebeu auxílio do policial Wagner, que ali chegava. Mesmo em superioridade numérica, os agentes da lei tiveram dificuldade de conter o réu e colocar as algemas.

A testemunha Wagner confirmou a narrativa.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Nessa linha:

“APELAÇÃO. ART. 329 DO CP. CRIME DE RESISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PROVA SUFICIENTE. O depoimento de policial, relatando que o acusado não obedeceu ao comando de colocar as mãos na cabeça e ainda entrou em luta corporal com ele, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de resistência. Apelação da defesa, improvida” (Apelação Crime Nº 70056953383, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 28/08/2014). O ato de prender e, em seguida, conter Higor durante a abordagem, não pode ser considerado, sob nenhum aspecto, como uma injusta agressão, uma vez que os policiais, revestidos de suas funções públicas, estavam fazendo o possível para efetuar o flagrante do indivíduo encontrado com drogas, de maneira segura e sem agressões desmedidas.

A ausência de lesões corporais nos policiais militares (e, conseqüentemente, de exame de corpo de delito correlato nos autos), por si só, não leva à absolvição do agente.

A configuração do delito de resistência não pressupõe ou estabelece, dentre as suas elementares, efetiva lesão corporal. A agressão, no contexto do crime de resistência, pode não deixar vestígios. Se verificada tal circunstância, como bem destacado pelo legislador no §2º do artigo 329 do Código Penal, implicará cumulação da pena com a prevista no artigo 129 do Código Penal. Caso contrário, a conduta subsume-se ao caput do dispositivo legal, hipótese dos autos.

Portanto, o acusado realizou condutas típicas - artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal - antijurídica e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar nos termos do artigo 68 do Código Penal, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

No tocante ao delito de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado.

A quantidade, a variedade e a natureza da droga apreendida - 392 porções individuais de maconha, 321 porções de cocaína, 249 invólucros plásticos contendo crack e 84 frascos de lança-perfume, totalizando 1.046 porções de drogas - não podem ser olvidadas nesta etapa da dosimetria.

A expressiva quantidade de droga justifica a elevação da sanção inicial. Muto extrapolou a quantidade que bastaria para caracterizar o delito de tráfico.

Ademais, as peculiaridades do caso seguramente demonstram que o réu não era um neófito na mercancia de drogas, do contrário não estaria na posse de tão expressiva quantidade de entorpecentes diversos (circunstância incomum para um iniciante no comércio espúrio). O acusado admitiu, em Juízo, que já tinha trabalhado para os traficantes em datas anteriores. Estava em viela conhecida como ponto de comércio

de drogas e foi apontado em investigação preliminar como sendo o 'abastece' da região (crível, diante da quantidade e variedade de droga apreendida), o que deixa claro a sua vinculação com alguma organização criminosa e dedicação a atividades delituosas.

Nessa linha:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS DROGAS APREENDIDAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS QUE, APESAR DE TEREM JUSTIFICADO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, NÃO DEFINIRAM A FRAÇÃO REDUTORA DO PRIVILÉGIO, MAS APENAS IMPEDIRAM O SEU RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) - Nesse compasso, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora, ao argumento de que o paciente se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se, além da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (64 eppendorfs contendo cocaína com peso líquido de 74,3 g; 14 porções de cocaína, na forma de "crack" com peso líquido de 4 g; 14 trouxinhas de "tetrahydrocannabinol", popularmente denominada de "maconha", com peso líquido de 47,9 g e 2 (dois) frascos que continham 11 ml de tricloroetileno), nas demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante do paciente. Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, de modo que, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Outrossim, é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Precedentes. (...) VI - A quantidade e a diversidade dos entorpecentes foram utilizadas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, bem como na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado, sendo, portanto, consideradas como circunstâncias desfavoráveis, a ensejar a aplicação do regime mais danoso, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no HC 419.489 SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27/02/2018)

Devem ser destacadas, ainda, as consequências do delito. A cocaína, em pó ou na forma de pedra (crack), tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador. O quantum de droga apreendido (mais de mil porções de droga, dentre cocaína, crack, maconha e lança-perfume, com peso considerável) demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social. O crime é de perigo abstrato.

Sobressai-se, no fato em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do acusado, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a "natureza" (ou "qualidade") e quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes ("HC 94655/MS MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CARMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma).

O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42, da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, "a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", e isto com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal".

Assim, fixo a pena base do delito de tráfico acima do mínimo legal, elevando-a em 1/5, índice adequado e proporcional às circunstâncias e consequências do crime, sob pena de inobservância do princípio da individualização da pena, o que perfaz 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Quanto ao delito de resistência, não se sobressai, no fato em tela, maior grau de censurabilidade da conduta do agente, inerente ao tipo penal em espécie. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 meses de detenção.

A seguir, presente a agravante genérica da reincidência (autos nº 0009295-

51.2015.8.26.0482 - roubo majorado - 3ª Vara Criminal de Presidente Prudente.

Trânsito em julgado em 15/02/2017. Cumpria pena em regime semiaberto quando se evadiu em 03/01/2022, cf. certidão criminal de págs. 41/43 e folha de antecedentes de págs. 44/46) e a atenuante da confissão espontânea, operando-se a compensação.

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juizes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" (Tema 585, REsp1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: "A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EResp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes" (AgRg no Resp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.). Ausentes causas de aumento de pena.

Quanto ao tráfico de drogas, não se aplica a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois não preenchidos os predicados legais. O acusado é REINCENTE.

O valor de cada dia-multa, diante da aparente situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o fechado para o delito apenado com reclusão (tráfico de droga) e o regime semiaberto para o delito apenado com detenção (resistência).

Mostram-se adequados à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito de tráfico de droga, seguido de resistência, circunstâncias em que foram praticados e suas consequências, que demonstram a periculosidade e ousadia do agente, aptas a reclamar reação severa, proporcional e seguramente eficaz, sob pena de impunidade.

Inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática do crime de tráfico nos moldes apurados nos autos - o agente portava mais de mil porções de droga, dentre maconha, cocaína, crack e lança-perfume - acrescido de resistência, denota periculosidade acentuada, personalidade e conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, sujeitando o agente à modalidade mais severa.

Outrossim, além da reincidência (crime anterior de roubo), o réu estava foragido. Cumpria a pena definitiva anterior quando se evadiu de estabelecimento prisional, voltando a delinquir. Na espécie, praticou crime equiparado a hediondo, HIGOR faz da prática de graves crimes o seu meio de vida, não se tratando, o fato em tela, de mero descuido em sua vida.

Nesse passo, regime mais benéfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", a par de não preenchidos os

requisitos objetivos e subjetivos dos artigos 33, §3º, 44 e 77, ambos do Código Penal, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Também não atenderiam aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, levando-se em conta as circunstâncias, gravidade dos crimes e desfavoráveis condições apresentadas pelo acusado. De modo contrário, injusta seria a situação daquele que pratica conduta menos gravosa, com condenação a pena mais branda, sujeito ao mesmo regime prisional daqueles que praticam crimes hediondos ou equiparados.

Outrossim, resultaria ilógica, nesta situação, a aplicação de tais benesses, sob pena de esvaziar-se o tratamento rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes (afastado o tráfico privilegiado), que, a propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitindo ao (à) Juiz(iza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não apenas em razão do quantum, mas pela gravidade concreta do crime e desfavoráveis condições subjetivas apresentadas pelo agente, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa. Acerca do assunto, outrossim, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

“É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria” (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado HIGOR HENRIQUE CARDOSO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329, caput, do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo (delito de tráfico de drogas) e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (delito de resistência), pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo preso (convertida a prisão em flagrante em preventiva - págs.48/52).

Em que pese a excepcionalidade da custódia cautelar, a medida ainda é necessária para o atendimento da finalidade da persecução penal.

Presente o *fumus commissi delicti*, consubstanciado nas declarações dos policiais civis, na confissão judicial do réu e na presente condenação. O *periculum libertatis* evidencia-se não apenas pela gravidade CONCRETA das condutas imputadas ao acusado, mas também pelas desfavoráveis condições subjetivas que apresenta.

Não se trata de presunção genérica de periculosidade de indivíduo assim acusado. Cuida-se de constatação cotidiana, reforçada pelo legislador pátrio: O tráfico de drogas é atividade que denota a criminalidade organizada; a disseminação das drogas

impõe aos usuários a prática de delitos antecedentes, contra o patrimônio alheio, para sua aquisição, e de delitos posteriores, geralmente contra pessoas, em razão da alteração do estado psíquico decorrente de seu consumo.

O acusado ostenta condenação anterior e irrecorrível por roubo majorado. É reincidente e cumpria pena em regime semiaberto quando se evadiu do sistema prisional, voltando a delinquir na condição de foragido. Na espécie, praticou crime equiparado a hediondo.

Não se cuida, na espécie, de apenas um desvio na vida do réu, que assim ostenta periculosidade acentuada e diferenciada, bem como conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade. O réu adotou a prática de graves crimes como meio de vida. Há fortes indícios de que, em liberdade, voltará a delinquir e se furtará à aplicação da lei penal.

As medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostram, portanto, adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo imprescindível para eficácia da persecução penal a manutenção da custódia cautelar. Não teriam idêntico efeito da prisão preventiva.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o acusado na prisão onde se encontra recolhido.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, oriundo do tráfico de droga em favor da União. Expeça-se o necessário.

De plano, não impugnados os laudos periciais:

a) e não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos;

b) autorizo a destruição da mochila, pochete e anotações. Oficie-se à autoridade competente.

Oportunamente, comunique-se Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) em relação à pena de multa, observe-se os parágrafos do artigo 479-A e 480, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, assim como o Provimento CG 05/22, providenciando-se o necessário.

d) Providencie-se a transferência do numerário apreendido nos autos para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD, informando sobre a decretação do perdimento da quantia apreendida e o local do depósito (comprovante de depósito juntado às pág.117).

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C. São Bernardo do Campo, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA